

1501166-65.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... como, afirmou já ter sido preso crime de tráfico de drogas.

Sob o crivo do contraditório o policial Cleber Matias alegou que o local é um ponto de tráfico de entorpecentes. Deparam-se com o réu no ponto de tráfico e de imediato ele confessou a prática de tráfico há uma semana, ganhando dez por cento do valor da venda e que o fazia por estar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501166-65.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501166-65.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147810/2022 - 02º D.P. DIADEMA, 25295714 - 02º D.P.

DIADEMA, 2147810 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cicero da Silva Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

CÍCERO DA SILVA LIMA, qualificado às fls. 05 e 16/17, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 31 de maio de 2022, por volta das 11h00, na Avenida Fundibem, altura do nº 100, Passagem Nara Leão, no bairro do Casa Grande, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 29 embalagens contendo 17,12g da droga cocaína, 29 embalagens contendo 9,66g da mesma droga, na forma de crack, e 18 embalagens contendo 16,7g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 10 e laudo de constatação provisória de fls. 12/14, agindo sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia (fls.50/53), o réu foi notificado e citado (fl.86), e apresentou defesa preliminar as fls.91/93, através do Defensor Público nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 16/08/2022 (fl.95).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do réu, discordando da redução máxima da pena entendendo que possa se dar no mínimo legal, discordando ainda de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional intermediário

Já o d. Advogado reiterou seu pedido de absolvição. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, reduzindo a pena e substituída com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal. Por fim, pleiteou a concessão da justiça gratuita.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.10, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls. 12/14 e 137/139), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.03/04), em OPERAÇÃO SUFOCO, realizavam DILIGÊNCIAS em viatura descaracterizada, pela Rua: Nara Leão s/n, local este conhecido notoriamente como ponto de vendas de drogas, oportunidade em que o indiciado CICERO DA SILVA LIMA, foi visto no local e assim detido e de imediato confessou a prática do tráfico e em seguida indicou o local onde as drogas estavam escondida, isto é, no mato ali próximo. Em busca pessoal não foram localizado valores em dinheiro e nem celular com o indiciado. Prosseguindo a busca a pochete que estava escondida pelo indiciado e que foi localizado no mato, com: 18 porções de maconha, 29 porções de cocaína, 29 porções de crack, todas embaladas e individualizada e provenientes da traficância. Indagado sobre os fatos, o indiciado confessou que estava no local dos fatos comercializando drogas, bem como, afirmou já ter sido preso crime de tráfico de drogas.

Sob o crivo do contraditório o policial Cleber Matias alegou que o local é um ponto de tráfico de entorpecentes. Deparam-se com o réu no ponto de tráfico e de imediato ele confessou a prática de tráfico há uma semana, ganhando dez por cento do valor da venda e que o fazia por estar desempregado. Ele indicou há três metros dele, num mato, havia uma sacola com as drogas, cerca de trinta porções de cada. Encaminhado ao DP, ele reiterou a confissão dele. Reconhece o réu e não o conhecia nem o viu antes.

Igualmente o policial Álvaro Malagutti respondeu que estavam na Operação Sufoco de combate ao tráfico de drogas e na viela citada, ponto notoriamente conhecido como de venda de drogas. O réu estava parado, em atitude suspeita. Questionado o que fazia no local ele confessou que estava comercializando entorpecentes e indicou um matinho onde estava uma pochete com as drogas (crack, maconha e cocaína). Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu, o desconhecendo até então.

O réu, em solo policial (fl.05) confessou que estava ali para a venda de drogas e que esta desempregado e por isso o que lhe restou foi vender a droga e que ganha 10% do valor da venda e que já fazia uma semana que ali estava fazendo as vendas. Perguntado sobre o local onde pegava as drogas, disse não saber de onde elas eram e que um desconhecido lhe passava a droga ali mesmo no ponto de venda. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Em juízo o acusado confessou e pediu desculpas alegando que era morador de rua e estava numa situação difícil. Foi morar embaixo do viaduto e ficou com uma dívida no tráfico e foi trabalhar para pagar. Tem passagem policial por tráfico também, e não foi a audiência porque estava morando na rua.

Logo, a confissão do réu não é prova única e veio corroborada pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu optou pelo silêncio em solo policial.

Não bastasse isso, tem-se o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Como visto, os policiais sempre afirmaram que o réu, por eles reconhecido, foi o indivíduo por eles avistado na biqueira já conhecida e quem tentou correr mas foi detido, acabando por confessar estar ali vendendo drogas, indicando onde havia escondido a bolsa contendo os narcóticos, que então foram localizados e apreendidos. E ainda que não presenciado ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza, ou mesmo a contração de uma dívida de drogas, o que não foi provado pela Defesa como lhe competia esse ônus, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Ressalto que o argumento de que os acusados Bruno e Lucas praticaram o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu: Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de

ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). TJ/SC: Desemprego não é motivo para excludente de ilicitude de tráfico 17/08/2021 - Admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável. O entendimento serviu de base para a 5ª câmara Criminal do TJ/SC negar apelação de um homem flagrado com meio quilo de cocaína em seu veículo, durante abordagem de policiais rodoviários. Processo nº 5004204-68.2020.8.24.0030).

A condição de usuário de drogas, que tão pouco foi provada pela Defesa, não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (76 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, especialmente pelo fato do réu ter um processo crime tramitando contra si, suspenso dada à sua revelia, e egresso (fl. 59), praticava o delito assemelhado a revelar personalidade amorala e dissimulada, distorção de caráter e ausência de sendo moral a justificar a elevação da pena, dado que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (76 no total) não reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Portanto, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 560 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, ausente circunstâncias agravantes. Mas presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012), a reduzir a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sendo o réu primário (fls.71/75), mas considerando a natureza de maior parte das drogas apreendidas, crack e cocaína, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, um verdadeiro câncer na nossa sociedade, e considerando o fato do réu estar traficando há uma semana na mesma biqueira, a demonstrar maior dedicação ao crime, me valho do redutor de 2/5, razoável e proporcional à maior gravidade da conduta, totalizando 03 anos de reclusão e 300 dias-multa.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior

reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves .

O quantum da condenação, a primariedade, mas a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, o fato do réu ter desrespeitado as condições de sua soltura por tráfico anterior a esse, quedando-se revel, desaparecido, e nessa condição persistiu na traficância, permitem o início de cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto a teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, somado à preponderância da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, e como ele mesmo afirmou, em situação de morador de rua, desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio

constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de cinco meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra CÍCERO DA SILVA LIMA, qualificado às fls. 05 e 16/17, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 300 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a data dos fatos corrigido monetariamente quando do efetivo pagamento.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, em 100 Ufesps, pois constituiu Advogado e não demonstrou hipossuficiência nem juntou declaração da mesma.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao IIRGD e TRE. Determino a incineração de todas as drogas.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA